

1500145-12.2022.8.26.0551

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ricardo Truite Alves

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/10/2022

... (intenção) mercantil da posse e da guarda da droga como tráfico consumado. O mero fato de o agente guardar ou ter em depósito drogas, ainda que a mando de terceiros, mesmo que sem intuito de lucro, configura o crime de tráfico de drogas, pois o tipo penal prevê como tráfico as condutas de guardar e ter em depósito, ainda que gratuitamente (art. 33, caput, Lei de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

3ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500145-12.2022.8.26.0551 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500145-12.2022.8.26.0551

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2089754/2022 - DISE-

DEL.SEC.LIMEIRA, 24018484 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 38/22/819 - DISE-

DEL.SEC.LIMEIRA, 2089754 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Josemar Barbosa de Oliveira

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Truite Alves

Vistos.

JOSEMAR BARBOSA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Conforme consta do incluso inquérito policial, no dia 1º de abril de 2022, por volta das 12h30min, na Rua Carminé Maimone, próximo ao numeral 20, Parque Residencial João Ometto, nesta cidade e comarca, o acusado trazia consigo, para comercialização com terceiros, aproximadamente 19,28g (dezenove gramas e vinte e oito decigramas) da droga cocaína, na forma de pó, acondicionada em quarenta e quatro microtubos plásticos, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (auto de exibição e apreensão, laudo de constatação provisória e laudo de exame químico toxicológico).

Segundo restou apurado, JOSEMAR realizava a venda ilegal de cocaína na localidade acima indicada, trazendo consigo a droga, quando foi avistado por guardas municipais realizando a entrega e o recebimento de algo do ocupante de uma motocicleta Honda CG125, em atitude típica de comercialização de entorpecente.

Ao perceberem a presença da viatura, o motociclista se evadiu e o denunciado arremessou o que segurava nas mãos sobre o telhado da garagem de uma residência, sendo abordado. Em revista pessoal, com JOSEMAR foi encontrada a quantia de R\$40,00 e um telefone celular.

Indagado, o denunciado confessou informalmente aos agentes municipais que realizava a venda de droga e que havia dispensado um pacote com cocaína. Em busca no telhado da garagem, os guardas municipais localizaram um pacote contendo quarenta e quatro microtubos plásticos com cocaína, que foi jogado pelo denunciado.

JOSEMAR foi preso em flagrante delito e perante a autoridade policial permaneceu em silêncio.

Oferecida a denúncia, determinou-se a notificação do acusado para que apresentasse defesa preliminar, que veio aos autos (fls. 103/107).

A denúncia foi recebida em 22 de julho de 2022 (fls. 108/110).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas, com interrogatório do acusado ao final (mídia).

Encerrada a instrução, as partes manifestaram-se.

O Ministério Público e a Defensoria Pública ofertaram memoriais (mídia).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A preliminar de ilegalidade da atuação da Guarda Civil Municipal é matéria que está entrosada com o mérito da ação penal e será analisada oportunamente.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 03), boletim de ocorrência (fls. 19/20), auto de exibição e apreensão (fls. 21/22), laudo pericial com resultado positivo para cocaína (fls. 26/28 e 76/78), bem como pela prova oral colhida no curso da persecução penal.

A autoria é certa.

Na fase policial, o réu disse que já foi processado por tráfico de drogas por duas vezes e receptação. Não quis falar a respeito dos fatos (fls. 07).

Em Juízo, o réu disse que tem 25 anos. Trabalha como pintor e pedreiro. Realmente estava vendendo drogas. Havia acabado de perder o serviço. Morava sozinho. Brigou com a sua mulher. Tinha filha para sustentar. Está arrependido. O que os guardas civis municipais falaram em audiência é verdadeiro. Tem antecedentes criminais (mídia).

A confissão judicial do acusado encontra amparo na prova oral colhida.

O guarda civil municipal Gustavo Zanella Salgado Cesar disse que estavam em

patrulhamento no bairro Parque João Ometto, perto do centro comunitário municipal, quando avistaram o réu fazendo uma possível venda de drogas para o piloto de uma motocicleta assim que saíram do local municipal. O motociclista deixou o local e, quando percebeu a presença da viatura, o denunciado arremessou algo em cima do telhado. Houve abordagem e revista pessoal, sendo encontrado no bolso da bermuda quantia em dinheiro. Indagado, ele admitiu a prática do tráfico. Ele disse que o pacote arremessado continha onze pinos de cocaína. O réu disse ainda que havia acabado de sair da cadeia e estava vendendo um pouco de drogas, pois estava sem dinheiro. Em seguida, usando um cabo de vassoura conseguiu puxar o pacote dispensado e constatou que se tratava de um embrulho contendo em seu interior quarenta e quatro porções de cocaína, motivo pelo qual deu voz de prisão. Não conhecia o réu até então. O local da prisão é um ponto forte de tráfico de drogas em Limeira e ali perto há um centro comunitário municipal que a Guarda Civil Municipal costuma fazer ronda por ser patrimônio municipal (mídia).

O Guarda Civil Municipal Marcos Paulo de Souza Ribeiro disse que havia terminado de fazer a ronda no centro comunitário municipal que fica ali ao lado. Quando saíram do local municipal, viram o réu fazendo uma possível venda de drogas para o piloto de uma motocicleta. Quando percebeu a presença da viatura, o réu arremessou algo em cima do telhado de uma casa. O acusado foi abordado e submetido a busca pessoal, sendo encontrado na sua posse quantia em dinheiro. Seu colega conseguiu recuperar o pacote que o réu dispensou e lá havia 44 porções de cocaína. Indagado, ele confessou que estava traficando, pois havia saído da cadeia e precisava de dinheiro. Deram voz de prisão (mídia).

Ressalto que o depoimento de guardas civis municipais neste caso é perfeitamente válido. É inadmissível alegar que seriam suspeitos. Não restou comprovada qualquer agressão, armação ou perseguição dos agentes públicos, que não tinham qualquer motivo aparente ou concreto para incriminar injustamente o réu.

Sobre a admissibilidade de tais testemunhos, cito o seguinte entendimento jurisprudencial:

“(...) Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, “a priori”, valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais “lato sensu”. Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10). (TJSP; Apelação 0003912-21.2015.8.26.0635; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro: 25/09/2017).

Pelo teor da prova oral colhida, guardas civis municipais realizavam patrulhamento de rotina pela Rua Carmine Maimone, perto de um centro comunitário municipal, local conhecido pela traficância ilícita, quando avistaram o réu em atividade suspeita,

entregando e recebendo algo a um motociclista, o qual se evadiu do local.

O réu, ao perceber a presença da viatura da Guarda Municipal, imediatamente lançou um objeto no telhado de um imóvel. Em seguida, foi abordado pelos agentes e, ao ser indagado, confessou a prática delitiva.

Foi encontrado no objeto arremessado 44 (quarenta e quatro) porções de cocaína, distribuídas em micro tubos de plástico para a comercialização. No bolso do réu, foram encontrados a quantia de R\$40,00 em dinheiro e um telefone celular.

Dessa forma, o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e à autoria do crime de tráfico, haja vista a quantidade, natureza e a forma como estavam embaladas as drogas (cocaína), a conduta do acusado quando da prisão, as circunstâncias e o local da abordagem, além da confissão judicial, tudo a apontar o réu como pessoa envolvida no tráfico de drogas.

Sobre o tema em comento, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo é remansosa:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito de drogas - Artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006 - Absolvição ou, ainda, desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas - Descabimento - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Palavra dos policiais militares - Credibilidade - Precedentes - Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão - Ausência de visualização de atos de mercancia - Irrelevância - Tipo misto ou de conteúdo variado - Condenação mantida (...) ". (TJSP; Apelação 0004568-50.2015.8.26.0126; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Caraguatatuba - Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/09/2017; Data de Registro: 11/10/2017).

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (...) Materialidade e autoria delitiva comprovadas, sobretudo diante dos relatos seguros dos policiais militares que participaram da diligência. Escusa ofertada pelo réu isolada no quadro probatório. Impossibilidade de desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06. Condenação mantida (...)". (TJSP; Apelação 0000137-25.2017.8.26.0571; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapetininga - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 01/03/2018).

"APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA BEM DEMONSTRADA, EM RELAÇÃO AO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS - PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI QUE MERECEM PRIMAZIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO, INCONSISTENTE A NEGATIVA DE AUTORIA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, LOCAL DA ABORDAGEM, CONHECIDO PONTO DE VENDA DE ENTORPECENTES, MODO COMO OS ESTUPEFACIENTES ESTAVAM EMBALADOS, QUANTIDADE SIGNIFICATIVA E NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA COMPATÍVEIS COM O TRÁFICO(...) (TJSP; Apelação 0002975-45.2014.8.26.0344; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 9ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Marília - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/09/2017; Data de Registro: 26/09/2017).

Segundo entendimento do saudoso Luiz Flávio Gomes:

"Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)" (GOMES, Luiz Flávio e CUNHA. Rogério Sanches (Coordenadores). Legislação Criminal Especial. Volume 6. São Paulo: Editora RT, 2009).

Note-se, ainda, que o acusado nada indicou de real para colocar dúvidas sobre a atuação dos guardas civis municipais, pois eles sequer conheciam o acusado e a abordagem foi de rotina.

Quanto à ação dos guardas municipais, tem-se que perfeitamente válida. É cediço que o artigo 144, § 8º, da Constituição Federal estabelece que a Guarda Municipal será destinada apenas à proteção de bens, instalações e serviços dos municípios, não tendo ela, portanto, a função de garantir a segurança, bem como investigar a prática de crimes. No entanto, referida limitação não significa que a Guarda Municipal não possa prender em flagrante quem estiver cometendo um delito.

"(...) 2. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10). Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP – Rel. Min. Moura Ribeiro – j. 27.05.14; RHC 45.173/SP – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 26.05.14 e HC 109.105/SP – Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima – j. 23.02.10). (...)". (TJSP; Apelação 0003302-14.2014.8.26.0627; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Teodoro Sampaio - Vara Única; Data do Julgamento: 31/10/2017; Data de Registro: 06/11/2017).

A situação trazida pela Defensoria Pública em audiência quanto à atuação da Guarda Civil Municipal não se assemelha àquela colocada em discussão por ocasião da decisão de uma das Turmas do Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.977.119 (cf. STJ, REsp n. 1.977.119/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022).

Decidiu-se naquele julgamento a respeito da limitação da atuação da Guarda Municipal em diligências investigativas, inerentes à atuação da polícia judiciária. No caso em tela, no entanto, na garantia da ordem pública, não se poderia exigir que os guardas civis municipais simplesmente acionassem a Polícia Civil ou Militar para que, apenas então, fosse efetuada a abordagem do acusado e apenas depois se verificasse as drogas dispensadas pelo agente, até porque os fatos ocorreram ao lado de um centro comunitário municipal.

No caso, não há evidência de atuação ilegal da ação da Guarda Civil Municipal, com

a observação de que os agentes públicos somente atuaram para a manutenção da ordem pública violada pela prática do crime de tráfico de drogas.

A respeito da atuação da Guarda Civil Municipal, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.281.774/SP, reafirmou a tese de que não há qualquer proibição à atuação dos guardas civis municipais, em conformidade com o voto do Ministro Alexandre de Moraes:

"Quero recordar a todos, inclusive, que, há dois anos, a lei que criou o Sistema Único de Segurança Pública incluiu a guarda civil metropolitana ou as guardas civis, dentro, obviamente, do âmbito de suas competências. Jamais, no nosso ordenamento jurídico, houve a impossibilidade de qualquer do povo, inclusive a guarda civil, realizar flagrante delito. Devo aqui também, em reforço à minha argumentação, colocar que, diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, no caso da guarda civil, dá-se a mesma coisa que qualquer do povo. A guarda civil pode - não está obrigada, mas não está proibida - realizar o flagrante delito. Aqui se inverte: ela não está obrigada, mas também não está proibida. (...).Entendo que essa interpretação do art. 144 é de cunho constitucional e tem relevância gigantesca, porque são inúmeras guardas civis em todos os municípios. Consequentemente, pelo cabimento do recurso os municípios." (STF, RE 1281774 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 21/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 18-08-2021 PUBLIC 19-08-2021).

Na mesma direção:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. REGIME FECHADO. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO". (STF, HC 212635 AgR, Relator(a): CÂRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 11/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 12-04-2022 PUBLIC 18-04-2022).

Aliás, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a Repercussão Geral do tema, no RE nº 608.588/SP, Rel. Min. Luiz Fux, em que se discute o alcance do art. 144, § 8º, da CF, envolvendo a atuação de guardas municipais (cf. STF, RE 608588 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 06-06-2013 PUBLIC 07-06-2013).

É inquestionável que a ação da Guarda Civil Municipal se revestiu de fundada suspeita, em conformidade com o artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, sendo descabida a aventada ilegalidade da busca pessoal.

Durante o patrulhamento rotineiro, o acusado foi abordado após demonstrar atitude suspeita na via pública, em local conhecido pela traficância ilícita, que resultou no encontro de drogas e dinheiro, havendo confissão informal aos agentes públicos e em solo judicial, circunstâncias estas que somadas geraram a fundada suspeita da posse de objetos ou substâncias ilícitas, que, por sua vez, autorizaram a busca em conformidade com os artigos 240 e 244 do Código de Processo Penal.

Nessa direção, confira-se:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. (...)
1. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for

determinada no curso de busca domiciliar. 2. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto (...)" 6. Agravo regimental desprovido". (STJ, AgRg no HC 685.437/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 01/10/2021).

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Hipótese em que o Tribunal de origem, diante das circunstâncias peculiares do caso - veículo parado em atitude suspeita, durante a madrugada, com quatro indivíduos em seu interior - entendeu haver fundada suspeita para a realização da abordagem pessoal, que resultou na apreensão de arma de fogo. A decisão vergastada está em consonância com o art. 244 do CPP e os elementos fáticos consignados no acórdão recorrido são legítimos para fins de busca pessoal. Rever a conclusão do aresto necessitaria do reexame do conjunto probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no AREsp 1403409/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 04/04/2019).

Não se exige a existência do efetivo comércio para a configuração do crime do artigo 33, caput, da Lei de Drogas. Basta a guarda, o transporte, o trazer consigo, ou a manutenção em depósito, com a finalidade de distribuição ou de entrega a terceiros para que o crime se consuma.

A lei penal pune a mera finalidade (intenção) mercantil da posse e da guarda da droga como tráfico consumado. O mero fato de o agente guardar ou ter em depósito drogas, ainda que a mando de terceiros, mesmo que sem intuito de lucro, configura o crime de tráfico de drogas, pois o tipo penal prevê como tráfico as condutas de guardar e ter em depósito, ainda que gratuitamente (art. 33, caput, Lei de Drogas).

Em se tratando de crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública, de modo que é condenável a simples possibilidade de distribuição, gratuita ou onerosa, do entorpecente.

Em comentários ao artigo 33 da Lei de Drogas, o saudoso Luiz Flávio Gomes preleciona:

"(...) Deve ser lembrado que algumas modalidades são permanentes, protraindo o seu momento consumativo no tempo e no espaço (p.ex., expor à venda, trazer consigo, manter em depósito, guardar etc.). A multiplicidade de condutas incriminadas parece inviabilizar a tentativa (...)" (GOMES, Luiz Flávio et al. Nova Lei de Drogas Comentada Artigo por Artigo: Lei 11.343/06 de 23.08.2006. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006).

É esse o caso dos autos.

Ainda, não há que se falar em princípio da insignificância, pois o entorpecente, mesmo em pouca quantidade, pode causar danos à saúde pública (bem jurídico protegido pelo tipo penal incriminador).

Desse modo, demonstrada a procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para os seus atos, passo à dosimetria da pena a ser aplicada.

Concernente ao crime de tráfico de drogas, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 são inteiramente favoráveis ao

réu, devendo a pena-base partir do mínimo legal, isto é, 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. A natureza e quantidade de drogas apreendidas no caso em tela não justificam a exasperação da pena-base pois não se trata de quantidade elevada.

Na segunda fase, observo que o réu é reincidente específico (Autos nº 0014839-21.2015.8.216.0320 – fls. 31/32). Dessa forma, elevo a pena em 1/6, para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, com pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por outro lado, como o acusado confessou o delito em Juízo e a sua confissão foi utilizada para formação do convencimento do julgador, reduzo a pena ao patamar inicial de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Nos termos da Súmula 545 do STJ, "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal", de modo que reconheço a sua incidência ao caso em apreço.

Na terceira fase, não reconheço a existência de bis in idem, não sendo caso de incidência do redutor previsto em lei, eis que o acusado é reincidente, em conformidade com jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RÉU REINCIDENTE. ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. REGIME INICIAL. APLICAÇÃO NOS TERMOS DO DOS ARTS. 59 E 33, § 2.º, DO CÓDIGO PENAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. (...) 2. Tratando-se de Paciente reincidente, não faz jus à aplicação da minorante inserta no § 4.º do art. 33 da Lei 11.343/06, nem tampouco resta caracterizado bis in idem diante da utilização da reincidência como agravante genérica e como fundamento para afastar o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, aplicável apenas ao réu primário e de bons antecedentes. Precedentes (...) 4. Ordem de Habeas Corpus denegada." (STJ, HC 231.511/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 23/08/2013).

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE, REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE. APLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/06. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. ORDEM NEGADA. 1. O § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 dispõe que as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente preencha cumulativamente os seguintes requisitos: ser primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa. 2. Reconhecida pelo Colegiado Estadual a reincidência específica do paciente, não há como aplicar a minorante, porquanto não preenchidos os requisitos legais para a concessão da benesse. 3. Não há ilegalidade na utilização da reincidência como agravante genérica e para afastar o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, porquanto é possível que um mesmo instituto jurídico seja apreciado em fases distintas na dosimetria da pena, gerando efeitos diversos, conforme previsão legal específica. 4. Ordem denegada". (STJ, HC 147.271/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2012, DJe 30/05/2012).

"PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, §4º, DA LEI N.º 11.343/2006. NÃO PREENCHIMENTO DE UM DOS SEUS REQUISITOS. REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. I - Inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois expressamente reconhecido na r. sentença condenatória que o paciente, por ser reincidente, não preenche os requisitos legais. II - Dentro dos limites legais, uma vez configurada a reincidência, a agravante deve ser aplicada. III - Não resta caracterizado bis in idem na utilização da reincidência como causa ensejadora da não aplicação da minorante do

art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, bem como agravante da pena, ante expressa previsão legal. Habeas corpus denegado". (STJ, HC 148.575/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 04/10/2010).

Não havendo outras causas de modificação da pena, torno-a definitiva em patamar mínimo legal.

Fixo cada dia-multa no mínimo legal.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, sobretudo pela natureza e quantidade das drogas em discussão, sem reconhecimento do redutor, além de ser reincidente específico.

Regime diverso do fechado para quem não faz jus ao redutor legal seria de extrema benevolência, por se tratar de crime assemelhado a hediondo.

Inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como pela suspensão condicional da pena em função da vedação do art. 44, da Lei nº 11.343/2006, além do quantum fixado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar JOSEMAR BARBOSA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no seu menor valor, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O réu não poderá apelar em liberdade, uma vez que permaneceu preso durante esse processo e ainda persistem os fundamentos que determinaram a prisão, em especial, a necessidade de garantir a ordem pública, ante as nefastas consequências de crimes contra o patrimônio para a sociedade em geral e a probabilidade concreta de solto voltar a praticar a atividade criminosa, devendo ser recomendado na prisão em que se encontra recolhido, anotando-se que é reincidente específico.

A detração penal será analisada em sede de execução, devendo se verificar a conduta carcerária do réu e os demais requisitos do processo de execução.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual ora concedida.

Defiro a incineração da substância entorpecente apreendida, com as cautelas de praxe, pela qual representou a autoridade policial.

Decreto o perdimento do dinheiro e telefone apreendido, porquanto fruto da traficância ilícita.

Após o trânsito em julgado, o nome do réu deverá ser lançado no rol dos culpados.

Publicado em audiência, saem os presentes intimados.

Limeira, 24 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA